

1500085-36.2021.8.26.0240

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Iepê

Foro: Foro de Iepê

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... para a consumação do delito de tráfico, basta que o agente pratique qualquer dos verbos contidos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é crime de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, para fins de tráfico.

A propósito:

"[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iepê

Foro de Iepê

Vara Única

Rua: Minas Gerais, 343, Iepe-SP - cep 19640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500085-36.2021.8.26.0240 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-36.2021.8.26.0240

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137023/2021 - DEL.POL.IEPÊ, 18023448 - DEL.POL.IEPÊ, 177/21/206 - DEL.POL.IEPÊ, 2137023 - DEL.POL.IEPÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

MARCO ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de maio de 2021, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Rio de Janeiro, nº 50, Residencial Oiti, nesta cidade e comarca de Iepê, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, dezesseis porções de maconha acondicionadas em invólucros plásticos, pesando no total 17,83g (dezessete gramas e oitenta e três centigramas) de massa líquida, droga capaz de causar dependência física e psíquica, conforme Portaria da ANVISA nº 344/1998, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia que o acusado, ao notar a presença dos policiais militares, empreendeu fuga, sendo que os policiais foram ao seu encalço e o localizaram debaixo de um tapume. Em seguida, os policiais efetuaram a revista pessoal e localizaram no interior de uma mochila, que o acusado portava, 16 (dezesseis) porções de maconha, já fracionadas e embaladas para a comercialização, bem como a quantia de R\$ 20,00 (vinte) reais.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05/06).
Exame de corpo de delito do acusado (fls. 22).
Boletim de ocorrência (fls. 23/25).
Auto de exibição e apreensão (fls. 26/27).
Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 31/32).
A decisão de fls. 49/52 homologou a prisão em flagrante, bem como cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial, concedendo a liberdade provisória a Marco Antônio Ferreira de Oliveira.
Alvará de soltura clausulado (fls. 53/54).
Laudo pericial (fls. 75/77).
Relatório final (fls. 79/81).
A certidão de fls. 93 e fls. 97/98 informou que o acusado encontra-se recluso pela prática de outro delito.
Notificado, o réu apresentou defesa prévia, alegando a invalidade da confissão informal. Pugnou ainda pela desclassificação do crime de tráfico, argumentando que se tratava de entorpecente para consumo pessoal (fls. 108/114).
A decisão de 26 de janeiro de 2022 recebeu a denúncia, bem como designou audiência de instrução, a qual ocorreu no dia 02 de maio de 2022, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como decretada a revelia do acusado (fls. 176/177).
O Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu, nos termos de denúncia.
A Defesa, em memoriais escritos, alegou a invalidade da confissão informal, pugnando pela desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal e, subsidiariamente, requereu que a pena fosse aplicada de forma mais branda (fls. 180/188).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente.
A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 23/25), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelas fotografias (fls. 28/30), pelo laudo definitivo de constatação da droga (fls. 75/77), bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também é incontestada e recai sobre o acusado.
A testemunha de acusação Marcos Francisco do Nascimento, policial militar, em sede inquisitiva (fls. 07), disse que efetuava patrulhamento de rotina juntamente com outro policial, quando, ao passarem pela Rua Santa Catarina, notaram que o réu empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura. Como o acusado já era conhecido nos meios policiais, existindo contra ele denúncias do seu envolvimento com o tráfico de drogas, resolveram sair em perseguição, sendo que Marco Antonio pulou muros e adentrou quintais de residências, mas foi encontrado escondido embaixo de um tapume defronte a um terreno baldio. Afirmou que ele portava uma mochila e no interior dela havia um saco plástico que continha 16 (dezesesseis) porções de maconha, já fracionadas e embaladas nos moldes do comércio, além da quantia de R\$ 20,00. Disse que o réu, informalmente indagado, assumiu ter adquirido a droga em Rancharia, de onde havia acabado de chegar e que já havia vendido duas porções por R\$ 10,00 (dez reais) cada. Diante disso, apresentaram os fatos para a deliberação da Autoridade de Polícia Judiciária. Em juízo (fls. 176/177), relatou que estava em serviço junto ao soldado Henrique, ambos na viatura patrulhando a Rua Santa Catarina, quando visualizaram subindo a Rua Rio de Janeiro um indivíduo, até então não identificado. Afirmou que o indivíduo empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura, subindo a referida rua e, por isso ocorreu a perseguição. Afirmou que o réu foi encontrado em frente a um terreno desocupado e que ele portava uma mochila, sendo que em seu interior havia cerca de 16 (dezesesseis) porções de maconha. Narrou que ao ser questionado, o réu alegou ter ido buscar o entorpecente na cidade de Rancharia/SP, dizendo que fazia a compra para revender na cidade de Iepê, pois ganhava certa quantia com tal comércio, sendo então conduzido até a delegacia. Respondeu, ainda, que a maconha encontrada estava dividida, em cerca de 16 (dezesesseis) ou 17 (dezesete) porções, em saquinhos plásticos individuais, não se

recordando se havia dinheiro. Pontuou que o réu havia dito no momento dos fatos que já havia vendido uma porção daquelas que carregava. Disse que não conhecia o acusado, pois nunca o havia abordado anteriormente. (mídia digital).

A testemunha de acusação Luiz Henrique Poleszuk Torquato, policial militar, em sede inquisitiva (fls. 08), disse que também é policial militar e que juntamente com outro policial, estavam em patrulhamento de rotina quanto na Rua Santa Catarina notaram que Marco Antonio Ferreira de Oliveira, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga pela Rua Rio de Janeiro. Afirmou que o réu já era conhecido nos meios policiais e, inclusive, existia contra ele denúncias do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Narrou que saíram em perseguição e o réu pulou muros e adentrou quintais de residências, mas foi encontrado escondido embaixo de um tapume defronte a um terreno baldio. Disse que ele portava uma mochila e no interior dela havia um saco plástico com 16 (dezesseis) porções de maconha, já fracionadas e embaladas nos moldes do comércio, bem como a quantia de R\$ 20,00. Afirmou que o réu confessou ter adquirido a droga em Rancharia, de onde havia acabado de chegar e que já havia vendido duas porções por R\$ 10,00 (dez reais) cada. Diante disso, apresentaram os fatos para a deliberação da Autoridade de Polícia Judiciária. Em juízo (fls. 176/177), relatou que era noite, e estava de serviço junto com seu colega Marcos, patrulhando a Rua Santa Catarina, quando avistaram o acusado subindo a Rua Rio de Janeiro. Disse que o réu, ao perceber a viatura, empreendeu fuga, sendo perseguido até um terreno baldio e que no local perderam o denunciado de vista, mas ao averiguarem, localizaram o réu, sendo este encontrado deitado num desnível. Afirmou que o réu portava uma bolsa e que nesta se encontravam os entorpecentes. Respondeu, ainda, que o acusado portava maconha, isto é, cerca de 16 (dezesseis) papелotes envoltos por plástico, aduzindo que é costume por praticantes de tráfico. Não se recorda se havia dinheiro, ou mesmo a quantidade do entorpecente. Narrou que o réu confessou que havia buscado o entorpecente na cidade de Rancharia/SP para comercializar em Iepê e que já havia vendido algumas porções no dia dos fatos. Não soube precisar quantas o réu disse que tinha vendido. Afirmou que já realizou inúmeras abordagens envolvendo o réu, porém até então não obtiveram êxito. Confirmou que o réu estava sozinho no momento da prisão. (mídia digital).

O réu Marco Antonio Ferreira De Oliveira, em sede inquisitiva (fls. 09), permaneceu em silêncio, alegando que se pronunciaria somente em juízo e após consultar um advogado. Em juízo, deixou de ser interrogado, uma vez que foi decretada a sua revelia.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o réu praticou o crime a ele imputado na exordial acusatória (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06).

A autoria do fato restou cabalmente demonstrada pelo depoimento dos policiais, que de maneira clara expuseram que o réu foi encontrado em via pública durante a noite, mantendo consigo uma mochila, sendo certo que ao notar o patrulhamento dos policiais, empreendeu fuga, ao passo que, quando encontrado, estava de baixo de um tapume, visando ocultar-se da iminente abordagem. Esta, quando efetuada, logrou êxito em encontrar os entorpecentes ora apreendidos.

A finalidade mercantil restou evidenciada por diversos elementos constantes dos autos, tais como a forma em que os entorpecentes se encontravam acondicionados. No caso concreto, já existiam informações, por meio de "denúncias", que davam conta de que o réu praticava a traficância.

Ademais, os relatos dos policiais são válidos, pois são servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprirem com retidão os seus deveres funcionais, agindo em regra de forma correta e nos limites legais, servindo os depoimentos como meio de prova idôneo, principalmente quando tomados em juízo, até que se prove ao contrário, ônus que cabe à defesa (STJ - HC nº 165.561/AM, rel. Min. Nêfi Cordeiro, j. 2.2.2016).

Pela prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, os policiais são capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente quando as versões por eles descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante e não desmerecidas no

contraditório.

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse em prejudicar o acusado, o depoimento deles pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. (STJ HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais militares quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 23/08/2016) (negritou-se).

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Note-se ainda que, para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi flagrado no próprio ato de venda da mercadoria ilícita. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização (RT 714/357).

Isso porque para a consumação do delito de tráfico, basta que o agente pratique qualquer dos verbos contidos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é crime de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, para fins de tráfico.

A propósito:

"[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ - HC211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

No que se refere à alegada confissão informal, cabe pontuar que, uma vez que não foi confirmada pelo acusado, nem mesmo em sede inquisitiva, tal elemento foi desconsiderado pelo Juízo; em outras palavras, não será sopesado como prova contra o acusado.

Por fim, a versão da i. Defesa restou isolada nos autos, uma vez que o entorpecente encontrado com o increpado não era para seu uso. A referida alegação é inverossímil, ante a quantidade de entorpecente apreendida, seu modo de acondicionamento, o fato de estar fracionado e pronto para venda, bem como as denúncias pretéritas acima mencionadas.

Com vistas a se elucidar a questão relativa à pequena ou grande quantidade de drogas apreendidas, tomemos a lição de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, in verbis: "Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114). (negritou-se)

Por conseguinte, vê-se claramente que o cálculo possibilita a confecção de cerca de 54 (cinquenta e quatro) cigarros de maconha com a quantidade que fora apreendida (17,83/0,33g - fls. 76). Resta cabalmente demonstrada a incompatibilidade da quantidade de entorpecente apreendida com o acusado com o uso para consumo próprio. Resulta óbvio que não poderia o réu fumar o equivalente a 54 (cinquenta e quatro)

cigarros da droga numa única noite.

Ademais, consoante já ponderado, a droga encontrada em poder do réu já estava fracionada, embalada na forma típica de comercialização e pronta para venda, o que corrobora o intuito mercantil da posse do estupefaciente. A espancar qualquer dúvida sobre a mercancia, em poder do acusado fora apreendido R\$ 20,00, denotando venda anterior à abordagem policial.

Os elementos carreados aos autos não permitem a desclassificação do delito para o de posse para consumo próprio, pois a quantidade e a forma de acondicionamento, conforme fotografia de fls. 29, apontam para a finalidade mercantil.

Descabida, portanto, a desclassificação para o delito capitulado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Para aferição se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico, deve-se analisar a quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais, bem como conduta e os antecedentes do agente, consoante art. 28, § 2º, da referida lei. Restou evidente nos autos que a condição de usuário foi arguida a fim de afastar a responsabilidade do réu sobre os fatos em análise, os quais foram devidamente comprovados pela prova oral e pericial, aliadas às demais circunstâncias, consoante acima exhaustivamente explanado.

A quantidade de droga apreendida não se coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos previstos no parágrafo 2.º, do art. 28 da Lei 11.343/06. No mais, “eventual condição de usuário do apelado não afasta, porsí só, a incidência do delito de tráfico de drogas, visto ser plenamente possível e comum, encontrar, em uma mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade” (TJSP Apelação Criminal nº 1500068-38.2018.8.26.0617, Rel. Des. Roberto Porto, j. 28.02.2020).

Segue o entendimento do C. STJ:

“(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.” (STJ - REsp1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018)

Observo, ademais, não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. Inviável sua aplicação, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais.

Isso porque o réu já foi preso em flagrante outras duas vezes (por fatos posteriores ao do presente feito), conforme autos de nº 1501273-94.2022.8.26.0542 (preso com 3 porções de cocaína e 16 porções de maconha) e nº 1501979-

14.2021.8.26.0542 (preso com 7 porções de maconha e 39 eppendorfs de cocaína), ambos da Comarca de Carapicuíba/SP e por tráfico de entorpecentes, o que denota dedicação às atividades criminosas. Desta feita, a reiteração da conduta, logo após ser preso e processado pelo delito que agora se julga, demonstra que o increpado fez do tráfico o seu meio de vida e modo de sustento, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de concessão do redutor.

Nesse sentido, remansosa a jurisprudência:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO E VENDEU UMA PORÇÃO DE COCAÍNA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE- CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES - REDUTOR DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, INAPLICÁVEL À HIPÓTESE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - REGIME PRISIONAL MANTIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Criminal 0003409-92.2017.8.26.0323; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

Saliente-se que o dispositivo em comento trata da figura do "traficante

privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual", no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Como já assentou o STJ, o objetivo da figura do tráfico privilegiado: é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Nesse contexto, o aludido § 4º do art. 33, ao prever que o acusado não deve se dedicar a atividades criminosas, não exige, em nenhum momento, que essa dedicação seja exercida com exclusividade. Portanto, a aplicação da minorante é obstada ainda que o agente exerça, concomitantemente, atividade profissional lícita. (REsp1.380.741-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe25/4/2016).

No presente caso, verifica-se que já recaíam contra o acusado diversas "denúncias" de que estava a praticar a mercancia espúria na cidade, o que também denota sua dedicação às atividades criminosas.

Aliás, é cediço que para que se possa praticar qualquer das condutas previstas no "caput" do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é suficiente a mera predisposição do agente para tanto. Não se consegue droga em grande quantidade em qualquer lugar. O traficante não pode efetuar a venda de entorpecentes onde bem entende, a menos que esteja sob a autorização da organização criminosa que controla a atividade ilícita na região. Caso contrário, sofrerá represálias.

Nesse ponto é válido ressaltar a interpretação precisa do C. STJ acerca da extensão do ARE 666.334 (rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado com repercussão geral) no sentido de que é possível utilizar a natureza e a quantidade de drogas para aumentar apenas na primeira fase e também para evitar a aplicação do privilégio; o que foi vedado pelo E. STF é utilizar tal critério para dosar o aumento e também para dosar a diminuição em patamar inferior a 2/3.

Veja-se:

Ainda que assim não fosse, a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.:Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

A propósito, confirmam-se os seguintes julgados:

[...] o Supremo Tribunal Federal preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e na definição do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assim, nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e fundamentem o não reconhecimento do tráfico privilegiado [...] (HC 342.870/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2016).

[...] Quando a expressiva quantidade de droga encontrada em poder do paciente é considerada para exasperar a pena-base e afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 - por denotar que o réu se dedicava às atividades criminosas - não significa tenha havido bis in idem na dosimetria da pena, porquanto o paradigma pretoriano preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e no dimensionamento, na modulação ou na definição do patamar daquela causa de diminuição, situação aqui não verificada, já que tal circunstância não serviu para dosar o quantum de incidência da minorante, mas para deixar de reconhecer a figura do tráfico privilegiado. [...] (HC 287.951/SP, Rel. Ministro GURGEL DEFARIA, QUINTA TURMA, DJe 13/10/2015).

Desse modo, no que se refere à causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se mostra inviável sua aplicação, pois de fato restou comprovado nos autos que o réu se dedica às atividades criminosas, fazendo da mercancia espúria o

seu modo de sustento. Isso porque não comprovou o exercício de atividade lícita, o que faz concluir pela mercancia espúria como meio de vida. Ademais, limitou-se a permanecer em silêncio em fase inquisitiva e foi revel em juízo, não havendo maiores esclarecimentos quanto à sua forma de sustento.

Assim, a imputação ministerial em desfavor do acusado merece acolhimento.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, a dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade para qual nada há de se destacar, os antecedentes também não se destacam, a conduta social, e a personalidade do agente são normais são tipo penal, os motivos e as circunstâncias nada há a ser destacado, tais que permanecem comuns ao tipo penal aqui tratado.

As consequências do delito, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, são negativas. Em se observando o impacto social do delito cometido na pacata cidade de Iepê (oito mil habitantes), percebe-se facilmente a total reprovabilidade de sua conduta, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, conseqüentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras

No que se refere à natureza da droga, tem-se que a maconha tem alta capacidade de tornar o usuário dependente químico, vinculando-o a uma deletéria engrenagem de consumo, onde a cada nova dose, maior quantidade se faz necessária a satisfazer o vício.

Não se pode descuidar do impacto que a comercialização de 17,83g de maconha - possível a confecção de 54 (cinquenta e quatro) cigarros de maconha com a quantidade que fora apreendida (17,83/0,33g - fls. 76) - possui nesta ordeira e pacata cidade do interior do Estado, notadamente se levar-se em conta a proporção população x usuários atendidos com a referida quantidade, bem como, abastecer os pontos de tráfico. A quantidade de entorpecentes é absolutamente expressiva, o que enseja exasperação considerável da pena-base.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, há a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal - fls. 23/25), razão pela qual minoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista o teor da súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo ser o caso de não se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pelos motivos na fundamentação expendidos, aos quais faço remissão, para se evitar repetição desnecessária.

Portanto, torno a pena acima definitiva.

Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

No caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal senão o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c art. 59, ambos do CP, haja vista o montante de pena aplicado e as circunstâncias judiciais negativas. Regime inicial menos rigoroso mostrar-se-ia insuficiente à prevenção e repressão do delito em tela. Ademais, conforme acima fundamentado, o acusado foi preso em flagrante em outras duas oportunidades pelo delito de tráfico de entorpecentes, o que aponta para sua dedicação às atividades criminosas, fazendo-se necessária, portanto, resposta punitiva proporcional, apta a fazer valer seu caráter sancionatório e dissuasório, tudo a demover o réu da seara delitiva. Não se pode

descurar, tampouco, da nocividade da droga consigo apreendida (maconha), bem como da expressiva quantidade, suficiente a confecção de mais de 50 cigarros do estupefaciente.

Inaplicáveis os institutos dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu MARCO ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo unitário legal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Decreto, ainda, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, a perda de eventuais valores monetários e objetos apreendidos em favor do FUNAD, pois, consoante fundamentado supra, provenientes da mercancia espúria.

Sem prejuízo, junte-se certidão de feitos criminais atualizada do réu.

Após o trânsito em julgado:

Notifique-se o condenado para o pagamento de multa no prazo de 10 dias, art. 50 do CP.

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da CF.

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. P.I.C.

Iepe, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA